

**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales -ITRC**

FUNDAMENTO PARA PROFERIR FALLO ABSOLUTORIO – Inexistencia de conducta disciplinable.

El funcionario XXXX fue comisionado para practicar diligencia de control y verificación de las obligaciones aduaneras y realizar la aprehensión, si a ello hubiere lugar, trasladar al depósito las mercancías etc.

Conforme al Acta de Inspección Aduanera de Fiscalización, el disciplinado consigna que se trasladó el 16 de agosto de 2012 hasta las instalaciones del muelle CONTECAR, situación que no ocurrió.

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 23

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD / Ausencia de conducta

“...La conclusión forzosa, entonces, no puede ser otra que la labor de administrar con calidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, mediante el servicio, la fiscalización y el control; facilitar las operaciones de comercio exterior y proveer información confiable y oportuna, con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano, misión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se cumplió, transformando la conducta reprochada al señor XXXX en inocua y, por los mismo, carente de ilicitud sustancial, tesis esbozada por el procurador del disciplinado y a la cual se encuentra eco por esta Subdirección de Investigaciones Disciplinarias.”

FUENTE FORMAL –LEY 734 DE 2002, art. 23

ANTI JURIDICIDAD / Ausencia de antijuridicidad.

“..., no ocurre frente al elemento de la antijuridicidad, bajo el entendido que acorde con lo argumentado hasta el momento la conducta resulta inocua, siendo imperativo absolver al disciplinado del cargo por el cual se le llamó a procedimiento verbal disciplinario.”

FUENTE FORMAL – LEY 734 DE 2002 – ARTICULO 35

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número de proceso:	1704-01-2012-284
Número y fecha del fallo:	17413-19, del 18 de julio de 2013
Asunto:	Fallo de Primera Instancia - Verbal
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Cumplidas las etapas de rigor y habiéndose dado traslado para presentar alegatos de conclusión, en sesión de audiencia de la fecha, la Subdirección Técnica de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC, en ejercicio de las facultades legales conferidas por la Ley 734 de 2002, los Decretos 4173 de 2011 y 0985 de 2012, procede a proferir fallo de primera instancia dentro del expediente disciplinario No. 1704-01-2012-284.

CARGO FORMULADO

“El señor XXXX, en su condición de Facilitador II Código 102 Grado 02 en la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, pudo incurrir objetivamente en una conducta descrita en la ley como delito sancionable a título de dolo, por cuanto el 16 de agosto de 2012 plasmó una falsedad en documento de índole público y con calidad de prueba ante la administración”

CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

CASO CONCRETO

Agotado el trámite previsto en los artículos 175 y siguientes de la Ley 734 de 2002, relativos al trámite del proceso verbal, es del caso proferir fallo de primera instancia, asistiéndole competencia a esta Subdirección de Investigaciones Disciplinarias acorde con las previsiones de los artículos 123 y 124 de la Constitución Política, y los artículos 25, 67, 75 y 76 de la Ley 734 de 2002, así como lo señalado en los decretos 4173 de 2011 y 0985 de 2012, conforme a los cuales se atribuyó competencia para conocer de procesos disciplinarios contra funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Conforme al Decreto 4173 de 2011, sin perjuicio del poder preferente del Procurador General de la Nación, la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales tendrá competencia para realizar las investigaciones de las conductas que por su trascendencia estén relacionadas con las faltas disciplinarias gravísimas establecidas en los numerales 1, 3, 17, 20, 30, 35, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 56, 58 y 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, entre otros, de los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

A su turno, sin perjuicio del mismo poder preferente, podrá asumir las competencias de las Oficinas de Control Disciplinario Interno sobre las demás faltas disciplinarias en que incurran los funcionarios de la DIAN, en aquellos casos que resulte necesario para la defensa de los recursos públicos.

Dicho lo anterior, los artículos 128 y 142 de la Ley 734 de 2002, aplicables a este contexto procesal por virtud a lo ordenado en el artículo 223 de la normatividad, determinan los requisitos probatorios fundamentales que debe contener todo fallo disciplinario. Dichas normas obligan al

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-284

fallador a sustentar su decisión final en pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso, las cuales deben conducir inequívocamente a la demostración de la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado.

La certeza corresponde a un estado mental de seguridad y, por lo tanto, de firme adhesión o asentimiento a la verdad de una proposición, fundada en una razón que excluye completamente y, por ende, libera del temor de la verdad de lo contrario. Certeza del hecho es la segura, firme, precisa y clara convicción que el operador disciplinario tiene acerca de la ocurrencia de una falta disciplinaria. Certeza de la responsabilidad es el convencimiento que adquiere el operador disciplinario acerca de la comisión de una conducta por parte del destinatario de la ley disciplinaria, resultante del análisis crítico y juicioso de las pruebas obrantes en la investigación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizará el material probatorio obrante en el expediente para concluir si el disciplinado es o no responsable de la comisión de la falta disciplinaria prevista en el numeral del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, conforme a la imputación elevada en el auto de pliego de cargos.

De la certeza sobre la ocurrencia de la falta

Para efectos del estudio de este aspecto en la presente decisión, se hace necesario efectuar un recuento de los hechos materia de investigación para concluir si, en grado de certeza, se tiene acreditada la existencia de la falta.

Por auto comisorio número 00223, de fecha 16 de agosto del año 2012, la Jefe de la División de Gestión de Fiscalización Aduanera (a) de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, comisionó al disciplinado XXXX "Para practicar diligencia de control y verificación de las obligaciones aduaneras y realizar diligencia de aprehensión si hubiere lugar a ello, trasladar al depósito con convenio con la Dian...a las mercancías en Declaración de Importación con levante automático No. y B/L: NBDA000154; Mercancía Consistente en : ABANICO, GORRAS, PARA NIÑO, CORREA, Importador: INVERSIONES CLOVER S.A.S. ubicadas en las instalaciones de CONTECAR, de la ciudad de Cartagena.

Frente a la comisión conferida por el auto comisorio atrás referido, el disciplinado XXXX elaboró el acta de hechos (ACTA DE INSPECCIÓN ADUANERA DE FISCALIZACIÓN) número 0409, de fecha 16 de agosto de 2012, señalando que "EN LA FECHA NOS PRESENTAMOS EL GRUPO OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN ADUANAS, EN LAS INSTALACIONES DE MUELLES CONTECAR CARTAGENA PARA REALIZAR INSPECCIÓN DE LAS MERCANCIAS AMPARADAS...LAS CUALES FUERON BLOQUEADAS PARA INSPECCIÓN FÍSICA POR EL GRUPO DE CARGA DE LA DIVISIÓN DE GESTIÓN A LA OPERACIÓN ADUANERA, UNA VEZ EN EL LUGAR SE NOTIFICO EL AUTO COMISORIO No. 223 . SE PROCEDIO A REALIZAR INSPECCION UN 10% DE LA MERCANCIA CONSISTENTE EN GORRAS Y SOMBRERO, ABANICO, CORREAS, DANDO COMO RESULTADO QUE DICHA MERCANCIA FGURAN EN SUS RESPECTIVAS DECLARACIONES DE IMPORTACION Y SE DESMOVILIZA EL CONTENEDOR, CON LO ANTERIOR SE FINALIZA LA PRESENTE DILIGENCIA DE CONTROL ADUANERO." Es de resaltar que según el acta, la diligencia se cumplió entre las 02:00 y las 04:00 p.m.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-284

Ocurrió que en realidad el señor XXXX no acudió a la hora señalada a la instalaciones del muelle de CONTECAR, luego tampoco efectuó la diligencia de inspección física en los términos descritos en el ACTA DE HECHOS (ACTA DE INSPECCION ADUANERA DE FISCALIZACIÓN), razón por la cual al momento de calificar el procedimiento y citarlo audiencia se indicó que objetivamente realizó una conducta descrita en la ley como delito sancionable a título de dolo, en desarrollo de sus funciones como Facilitador III de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, adscrito a la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, relativo a la falsedad ideológica en documento público, del artículo 286 del Código Penal.

Así quedó acreditado dentro de la actuación disciplinaria, a través de diferentes medios de convicción oportuna y legalmente allegados, como son el reporte de ingreso por fecha y tiempo de permanencia del señor XXXX dentro de las instalaciones de la Sociedad Portuaria Regional Cartagena⁵, la impresión de la consulta de movimiento del contenedor objeto de la supuesta inspección⁶, el informe del Patrullero de la POLFA y la diligencia de testimonio ofrecida por el señor Agente Aduanero GARAY, conforme a los cuales se acreditó que el señor XXXX no asistió a la hora señalada a las instalaciones de CONTECAR, luego, no cumplió la diligencia de inspección en los términos reseñados en el acta de la misma.

Conforme a los medios probatorios referidos, para el 16 de agosto del año 2012 el disciplinado XXXX no se presentó en las instalaciones de Contecar, no ingresó a las instalaciones de la Sociedad Portuaria y, por ende, tampoco hubo movimiento del contenedor materia de inspección a la hora de la supuesta diligencia de inspección, incurriendo en una situación contraria a derecho al señalar la realización de una diligencia que nunca se cumplió.

En ese orden de ideas, al consignar una situación contraria a la verdad, dentro de un documento con valor probatorio, en desarrollo de las funciones propias del cargo por parte del servidor público de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, objetivamente se presentó la comisión de la conducta delictiva del artículo 286 del Código Penal, y la incursión en la infracción disciplinaria gravísima del numeral 1o del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Ello es así, por cuanto atendiendo su designación para cumplir diligencia de control y verificación de las obligaciones aduaneras, de la mercancía relacionada en la declaración de importación del documento de transporte NBDA000154, consignó dentro de un documento con valor probatorio (ACTA DE HECHOS - ACTA DE INSPECCIÓN ADUANERA DE FISCALIZACIÓN) una falsedad, al asegurar haber efectuado una diligencia de inspección que, como ya se anotó, jamás cumplió en los términos descritos en el documento referido.

Con su actuar el 16 de agosto del año 2012, en la elaboración del acta de hechos visible a folio 12 de la actuación, agotó objetivamente la conducta delictiva del artículo 286 del Código Penal, bajo el entendido que para ese momento era servidor público, extendió un documento con carácter suasorio contentivo de una situación ajena a la realidad, atendiendo sus funciones como Facilitador III de la DIAN, comisionado para la práctica de la inspección a la mercancía del Importador INVERSIONES CLOVER S.A.S.

Resultado de lo expuesto, se cumple así el abastecimiento del primero de los requisitos normativos para emitir fallo de primera instancia, la demostración de la falta disciplinaria, en razón de la acreditación de la comisión objetiva de una conducta descrita en la ley como delito, sancionable a título de dolo, con ocasión de sus funciones como miembro de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, adscrito a la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena.

Es importante en este punto referir, que la Subdirección no comparte los planteamientos referidos a la ausencia de tipicidad por falta de valor probatorio del documento cuestionado, por cuanto considera que más allá que la inspección fuera o no obligatoria, el deber del disciplinado era consignar la verdad en el acta de hechos por los efectos que la misma representaba para la propia administración, ya que no se debe olvidar que fue gracias a ésta que el contenedor pudo ser retirado de los muelles de Contecar, situación que impone concluir que el documento tenía valor probatorio porque acreditó ante la Policía Fiscal y Aduanera el cumplimiento de un requisito para permitir el tránsito de la mercancía por el territorio nacional.

Por lo anterior, no se acogerá el argumento plateado por la defensa, siendo necesario reiterar el cumplimiento del requisito de certeza sobre la comisión de la falta disciplinaria imputada en el auto de citación a audiencia.

De la certeza sobre la ilicitud sustancial

Demostrado como se encuentra que existió un quebrantamiento de la norma, debe analizarse si éste merece reproche disciplinario, mismo que se hace necesario cuando el comportamiento considerado como típico vulnera o pone en peligro, de manera sustancial, el deber funcional exigible al disciplinado.

Con relación a la ilicitud sustancial, el artículo 5o de la Ley 734 de 2002 dispone que la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna, orientado éste a asegurar una correcta administración pública, es decir, diligente, eficiente, ética, moral, transparente, legal, en procura del cumplimiento de los objetivos estatales. Precisamente por ello, se reconoce que la ley disciplinaria tiene como finalidad específica la prevención y buena marcha de la gestión pública, así como la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores públicos que los afecten o pongan en peligro.

Sobre este tópico no ha sido poca ni pacífica la discusión a niveles jurisprudencial y doctrinal, por cuanto existen posiciones que pregonan la ilicitud a partir del simple desconocimiento del deber, como aquellas que demandan la materialización de un daño o el puesto real en peligro del bien jurídico de la administración pública, para concluir que la conducta del servidor público resulta antijurídica en los términos del artículo 5o de la Ley 734 de 2002.

En criterio de esta Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, lo correcto no es demandar la materialización de un daño efectivo (antijuridicidad material), como se plantea por la defensa, ni tampoco identificar la ilicitud sustancial con el mero quebrantamiento formal del deber, sino que es necesario estudiar la conducta del agente dentro del ámbito de la función social que constitucionalmente y legalmente le corresponde como servidor público para arribar a la

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-284

conclusión de la necesidad de un juicio de reproche en su contra, desde el punto de vista de la antijuridicidad.

Dicho lo anterior, es necesario precisar unos aspectos en torno a los hechos materia de investigación, para posteriormente concluir sobre los mismos si éstos resultan o no antijurídicos conforme a los parámetros del artículo 5o de la Ley 734 de 2002.

Como primer elemento, debe señalarse que contrario a lo plasmado en el informe de la situación a la autoridad disciplinaria, el contenedor individualizado con el serial TTNU5291988, contentivo de las mercancías importadas por la firma INVERSIONES CLOVER S.A.S., a través de las declaraciones de importación 482012000359309-9, 482012000359307-4 y 482012000359282-9, no fue perfilado o bloqueado ni en control inicial ni en control posterior, otorgándosele el correspondiente levante, que es el acto por medio del cual la autoridad aduanera, en este caso la DIAN, permite a los interesados la disposición de la mercancía, previo el cumplimiento de los requisitos legales o el otorgamiento de garantía, cuando a ello haya lugar.

Así está acreditado a través de la reproducción del auto comisorio otorgado al disciplinado, la comunicación dirigida al Fiscal 51 Seccional de Cartagena y el testimonio ofrecido por la Directora Seccional de Aduanas de la misma ciudad, recaudado conforme a solicitud del procurador disciplinario del servidor público.

En segundo lugar, el expediente administrativo adelantado por el Grupo de Investigaciones Aduaneras I de la misma Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, luego de adelantar las actuaciones pertinentes, por decisión número 06185 del pasado 24 de septiembre de 2012, determinó archivar la investigación aduanera y aceptar las declaraciones de importación presentadas por el importador INVERSIONES CLOVER S.A.S., por encontrar que las mercancías aprehendidas coincidían con las descripciones declaradas en las declaraciones de legalización, que las unidades aprehendidas por la POLFA estaban inmersas en las cantidades registradas, que el valor total de los tributos aduaneros por la importación de las mercancías se cancelaron en las declaraciones iniciales y porque el valor pagado por concepto de rescate por el 50% del valor en aduana de la mercancía corresponde al que se debía pagar teniendo en cuenta las características descritas de las mercancías aprehendidas coincidiendo con las que se declararon en los documentos de legalización.

Finalmente, acorde con el testimonio ofrecido por el superior funcional del disciplinado, la situación acaecida en torno al contenedor de la firma INVERSIONES CLOVER S.A.S., no se presentó de forma furtiva u oculta, por decirlo de alguna manera, por el contrario, fue expuesta por el disciplinado XXXX antes de su desarrollo, a efectos de exponer las razones que determinaron la realización de una inspección de tipo documental y no física frente a la mercancía.

Debe recordarse en este punto que, como lo informó el servidor público investigado y se acreditó dentro de la actuación, para el 16 de agosto de 2012 el Grupo Operativo estaba diezmado por situaciones administrativas de sus integrantes, toda vez que el Coordinador disfrutaba de un periodo de vacaciones y otra de las integrantes estaba en calidad de encargo dentro de otra área de la Dirección Seccional de Cartagena.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-284

Pues bien, la suma de los anteriores elementos llevan a esta Subdirección de Investigaciones Disciplinarias a concluir que, si bien es cierto objetivamente se presentó la conducta de falsedad ideológica en documento público, producto de la inserción de una situación ajena a la realidad en documento con fuerza probatoria (cumplir una inspección física sobre una mercancía), la misma carece del elemento de antijuridicidad porque no se afectó la función social asociada a su actividad funcional, identificándonos con la postura del señor defensor de confianza en este aspecto.

Nótese que la misma Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales nunca encontró razones para perfilar o bloquear la mercancía en cuestión y, por el contrario, ofreció a la misma su levante en forma automática, situación que obliga concluir hubo ausencia de elementos de juicio para pensar que la mercancía podría corresponder a contrabando y generar un detrimento de índole patrimonial por el no recaudo de los tributos derivados de la importación.

En igual sentido, y posterior a la aprehensión de la mercancía por parte de la Policía Fiscal y Aduanera, la autoridad aduanera no decretó el decomiso de la mercancía porque determinó que la misma estuvo correctamente importada, más allá de la diferencia en la descripción que determinó un examen técnico, cumplido el cual solo hubo lugar al pago de un tributo por parte del importador, derivado del error en la descripción de los bienes, situación que como relató la Jefe del Grupo de Investigaciones Aduaneras I no constituye la existencia de contrabando alguno.

La conclusión forzosa, entonces, no puede ser otra que la labor de administrar con calidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, mediante el servicio, la fiscalización y el control; facilitar las operaciones de comercio exterior y proveer información confiable y oportuna, con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano, misión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se cumplió, transformando la conducta reprochada al señor XXXX en inocua y, por los mismo, carente de ilicitud sustancial, tesis esbozada por el procurador del disciplinado y a la cual se encuentra eco por esta Subdirección de Investigaciones Disciplinarias.

Sobre este elemento, la Corte Suprema de Justicia en radicado 12.139, con ponencia del H. Magistrado RICARDO CALVETE RANGEL, en decisión del pasado 28 de septiembre de 1997, señaló:

"La antijuridicidad de la acción de incluir en un escrito público mentiras no va implícita en la tipicidad, es necesario que con ello se afecte el interés jurídico tutelado, aunque sea potencia ;mente, ya que si la conducta resulta inocua la falsedad no puede ser objeto de reproche penal, pues de ser así se sancionaría el hecho realizado al margen de cualquier incidencia social, despojando al derecho penal de su naturaleza de protector de bienes jurídicos para convertirlo en un instrumento ciego de represión.

Dicho de otra manera, lo que es imputable a una persona como delito de falsedad ideológica en documento público no es simplemente que consigne en un escrito expedido como funcionario público puntos que no corresponden a la verdad, sino que además esa falsedad tenga al menos

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-284

potencialmente capacidad de daño, que es lo que falta en el caso que nos ocupa, en donde se dejó de anotar una verdad que sirvió para hacer efectiva la libertad concedida a los procesados, para consignar una mentira innecesaria."

Al respecto, la Procuraduría 1 Delegada General de la Nación, en radicado 025- 85916-2003, decisión del 29 de octubre del año 2007, indicó:

"otra parte, para deducir responsabilidad disciplinaria a una persona no basta demostrar que ella ha desconocido el tenor literal de una disposición legal sino que además es indispensable acreditar dentro de la investigación que con dicho comportamiento se afectó el bien jurídico que el legislador pretendió resguardar mediante la creación de la respectiva norma.

El bien jurídico tutelado que protege la ley disciplinaria es el adecuado funcionamiento del servicio para el cumplimiento de los fines y funciones del Estado pero no todo abuso de derechos incumplimiento de sus deberes violación de las prohibiciones o incursión en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses lesiona el bien jurídico tutelado.

Se tiene que el artículo 14 de la Ley 200 de 1995 proscribire toda forma de responsabilidad objetiva en materia disciplinaria y dispone que las faltas solo son sanciona bies a título de dolo o culpa y en este disciplinario no se encuentra demostrado que... haya actuado con dolo o intencionalidad de desplegar una conducta que causara daño a otras personas o a la Administración."

Corolario de lo expuesto hasta el momento, es que, si bien se encuentra abastecido el presupuesto de certeza sobre la demostración de la falta, no ocurre lo mismo frente al elemento de la antijuridicidad, bajo el entendido que acorde con lo argumentado hasta el momento la conducta resulta inocua, siendo imperativo absolver al disciplinado del cargo por el cual se le llamó a procedimiento verbal disciplinario.

Sin embargo, es oportuno señalar que esta decisión es consecuencia de las situaciones particulares alrededor del contenedor tantas veces referido, pero en todo al disciplinado le asiste un deber de verdad en el desarrollo de sus funciones, por lo que deberá asumir las mismas aplicando en todo momento dicho deber, a fin de evitar verse inmerso en situaciones similares a futuro.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

PRIMERO: ABSOLVER DE RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA al funcionario (XXXX), en su condición de Facilitador III, en funciones en la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, del cargo imputado y por el cual se le llamó a proceso verbal disciplinario, acorde con las razones expuestas.

Continuación de acta de audiencia del fallo en primera instancia dentro del expediente 1704-01-2012-284

SEGUNDO: La presente decisión queda notificada en estrados. Se hace saber que contra la misma procede el recurso de apelación, en los términos de los artículos 110, 111, 112 y 115 de la Ley 734 de 2002.

TERCERO: Comunicar la presente decisión a la Procuraduría General de la Nación.

Acto seguido se concede el uso de la palabra al señor defensor, para que manifieste si desea presentar recurso contra el fallo de primera instancia, a lo cual manifestó: No señor. En virtud de lo anterior, se procede a clausurar la presente diligencia de audiencia, siendo la hora de las 10:00 a.m.

JORGE ADRIANO MORENO PONCE
Subdirector Investigaciones Disciplinarias -ITRC
Director del Proceso

ABOGADO DEFENSOR

SECRETARIO AD HOC

Proyectó: Dr. Giovanni Acero – Secretario Ad-Hoc